



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 94/12+314/12

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

התובעים: 1. **מלי דוד**
(הנתבעים ב-314/12) 2. **עוזי דוד**
ע"י ב"כ עו"ד עוז כהן

- נ ג ד -

הנתבע: 1. **יורם פאר**
(הנתבעים ב-94/12) 2. **אופירה פאר**
ע"י ב"כ עו"ד אלון נחמד

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק דין זה בעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, בחלוקת שימוש של הרכוש המשותף, ובהתקנת מזגנים.

א. העובדות הצריכות לעניין

1. עסקינן בבית משותף המוכר כגוש 30424 חלקה 18 והמצוי ברחוב לאה פורת 5, בגבעת משואה, ירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). על פי צו רישום הבית המשותף, מורכב הבית מאחד עשר מבנים ובסך הכל 40 דירות. הצדדים להליך זה גרים בבית המסומן בתשריט ובצו רישום הבית המשותף כמבנה X (להלן: "**המבנה**"), המונה שתי דירות אלו בלבד.

2. התובעים בתיק 94/12 והנתבעים בתיק 314/12 (להלן יכוננו למען הנוחות - "**דוד**") הם בעלי זכויות החכירה בחלקים שווים בתת חלקה 35. מדובר בדירת קוטג' המשתרעת על פני קומת המרתף, קומת הקרקע והקומה הראשונה. שטחה 125.3 מ"ר והחלק ברכוש המשותף השייך לה הוא 15/638. לדירת דוד מוצמד, על פי הרשום במרשם המקרקעין, שטח קרקע בגודל של 40.3 מ"ר, שטח קרקע נוסף בגודל של 34.3 מ"ר וגג בגודל של 112.7 מ"ר.

3. הנתבע בתיק 94/12 ויחד עם אשתו, הגב' אופירה פאר, התובעים בתיק 314/12 (להלן: "**פאר**") הם בעלי זכויות החכירה בחלקים שווים בתת חלקה 37- דירה בקומה השנייה של הבית המשותף בשטח של 94.6 מ"ר וכן מרפסת לא מקורה בשטח של 8.3 מ"ר. לדירה זו 10/638 חלקים ברכוש המשותף. לדירת פאר צמוד משטח בטון ומדרגות בגודל של 10 מ"ר, משטח בטון נוסף בגודל של 1.2 מ"ר, גג בשטח של 112.7 מ"ר וכן מחסן החולש על פני 9.5 מ"ר והמצוי בקומת הקרקע (להלן: "**המחסן**").

4. הכניסה למחסן היא דרך שביל הגישה לדירות המבנה. שביל גישה זה, בהתאם לתשריט הבית המשותף, הנו רכוש משותף של כל דירות הבית המשותף. כעולה מתשריט הבית המשותף, בצמוד למחסן, מצוי חלל



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שאיננו צמוד לאף אחת מדירות הבית המשותף בכלל והמבנה בפרט ולפיכך מהווה, גם הוא, רכוש משותף (להלן: "החלל").

5. גג נוסף, בגודל של 112.7 מ"ר, מוצמד בחלקים שווים לדירת דוד, דירת פאר והדירה הידועה כתת חלקה 36.

6. התביעה (תיק 94/12) הוגשה ביום 10.7.12. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסדר מוסכם, הגישו פאר תביעה נפרדת כנגד דוד (314/12) ביום 29.11.12, על טיבה נעמוד בהמשך. בקשת פאר לאיחוד הדיון בשני התיקים נדחתה בהחלטתי מיום 23.12.12, וזאת מהטעמים המנויים שם ובין היתר מאחר שסברתי כי איחוד הדיון בתיקים, בהינתן הפערים הדיוניים בהם נמצא כל אחד מהם, עלול להשקות את בירור התביעה מעבר לדרוש.

7. במהלך דיון ההוכחות בתיק 92/12, אשר התקיים ביום 17.1.13, הרחיבו שני הצדדים בחקירותיהם באופן בו למעשה התבררו גם הסוגיות הנוגעות לתביעה 314/12. במצב דברים זה הצעתי לצדדים בתום דיון ההוכחות כי פסק הדין יינתן בשני התיקים גם יחד. ב"כ דוד, עו"ד כהן, הודיע במעמד זה על הסכמתו ואילו ב"כ פאר, עו"ד נחמד, הודיע ביום 31.1.13 כי ילאור טיב החקירות והראיות שכבר הוגשו לתיק 94/12 מסכימים הם להגשת סיכומים גם בתיק שבכותרת (314/12 - י.ע.ש), וזאת תוך שמירה על זכויותיהם לעניין העלאת הערות ואו התנגדויות לעצם הגשת נספחי כתב ההגנה ואו לתוכנם". אי לכך, בו ביום הוריתי על הגשת הסיכומים מטעם הצדדים בשני התיקים גם יחד. ומכאן, ניתן פסק דין זה ביחס לשני התיקים.

8. ביום 17.1.13, מיד בתום שמיעת הראיות בתיק, ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

ב. טענות הצדדים

תיק 94/12

עיקרי טענות דוד

9. לטענת דוד, פאר השתלטו על החלל ועושים בו שימוש ייחודי. לטענתם, ייעוד שטח המחסן והחלל שצורף אליו שונה, ללא כל היתר או הסכמה, לאולפן הקלטות וחדר ללימוד נגינה אליו מגיעים תלמידים לאורך כל שעות היום. נטען עוד כי פאר לא קיבל היתרי בנייה כדין להשתלטות על חלל זה וכי הכניסה לאולפן ההקלטות מתבצעת משביל הכניסה הפרטי לדירתם. כמו כן טענו דוד בתביעתם כי פאר מבקש להתקין מזגן בשביל הכניסה לביתם.

10. הסעדים שהתבקשו בתביעה זו הם:

- א. החזרת החלל הריק לקדמותו כחלק משותף בנכס, לשימוש כלל הדיירים.
- ב. להחזיר את המחסן לייעודו כמחסן כפי שקיבל אותו מהקבלן וכפי שהוא רשום בטאבו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. לאסור על הנתבע לקיים שיעורי נגינה במחסן.

ד. לאסור על התקנת המזגן".

11. לטענת דוד, על מנת לבצע הצמדה של רכוש משותף לדירת פאר, היה צורך לתקן את צו הבית המשותף.
12. באשר להתקנת המזגן טוענים דוד, כי מכוח הוראות התקנון המוסכם, נדרשת לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות. עוד נטען, כי גם לפי הפסיקה יש להידרש להסכמת כל בעלי הדירות או האסיפה הכללית על מנת לפגוע בקירות החיצוניים של הבית המשותף, המהווה רכוש משותף. בעניין זה מפנה ב"כ דוד, עוה"ד כהן, לע"א 93/84, ש' קדמי נ' י קווין ואח', פד"י מ(1) 724, ע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פד"י כט (2) 39, ע"א 515/65, רבובסקי ואח' נ' גלסברג ואח', פד"י כ(2) 290, וכן ע"א 93/81 א' אליאס ואח' נ' שיפר ואח', פד"י לו 2 444 וכן ע"א 1182/99, שפלד נ' מוברמן, דינים מחוזי, לג (2) 112.
13. באשר לשימוש שביצע פאר במחסן נטען כי המחסן נועד לאחסון חפצים ולא ללימודי נגינה או מגורים, כפי שנעשה בפועל, וכי השימוש במחסן שלא בהתאם ליעודו פוגע בהם.
14. לטענת דוד, יש לפרש את המונח "פגיעה" המופיעה בסעיף 2 לתקנון המצוי, כפגיעה מכל סוג שהוא, גם קלת ערך, וכן כל פגיעה העשויה לשנות את אופי הבית ולהביא לירידת ערך הדירות בו.

עיקרי טענות פאר

15. בכתב הגנתו העלה פאר מספר טענות מקדמיות:
16. ראשית, נטען כי דין התביעה, ככל שאינה מתייחסת לרכוש המשותף, להידחות על הסף, בהיעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום המקרקעין לדון בה. לטענת פאר, ככל שיש לתובעים טענה בדבר מטרד (רעש, הפרעה עקב השימוש במחסן של פאר, לכלוך, אי סדר, תנועת תלמידים) הרי שהסמכות לדון בה נתונה לבית משפט השלום. בעניין זה מפנה פאר לע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1) 231.
17. שנית, טוען פאר כי דינה של התביעה להיות מסולקת על הסף גם מאחר ולדיו היא טורדנית וקנטרנית ומוגשת בחוסר תום לב ומתוך ניסיון להפעיל עליו לחץ לא הוגן.
18. שלישית, לטענת פאר נעדרת התביעה עילה – הן מאחר והוא טרם התקין מזגן והן מאחר ולמקרא כתב התביעה לא ברור מהן העילות עליהן מבססים דוד את דרישותיהם. לטענת פאר, גם טעם זה מצדיק את סילוקה של התביעה על הסף.
19. טענה מקדמית נוספת, רביעית במספר, שמעלה פאר היא טענת שיהוי ומניעות. פאר סבור כי התביעה לוקה בשיהוי ניכר וויתור שכן, לטענתו, במשך תקופה של למעלה מעשור הייתה הסכמה בין שלושת בעלי דירות המבנה בנוגע לשימוש, חזקה ייחודית ועבודות שעושה כל אחד מהם ברכוש המשותף. לטענת פאר, בנסיבות אלו יש לראות בהתנהגות התובעים ביטוי לויתור והסכמה לפריצת החלל ושימוש בו. בהקשר זה נטען עוד כי דוד מנועים ומושתקים מלדרוש את השבת המצב לקדמותו מאחר ופאר הסתמך על התנהגותם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מזה למעלה מעשור ועל סמך הסכמתם פעל והשקיע במחסן ובחלל. נטען כי הרשות שניתנה לו בנסיבות העניין היא רשות בלתי הדירה.

20. לטענת פאר, ההסכמה שנתנו דוד לפריצת החלל ניתנה החל משנת 1999, עת נכנס הוא לביתו, והיא הסכמה מפורשת אשר לא סויגה מעולם. לחלופין נטען, כי אף אם אין מדובר בהסכמה מפורשת, שתיקתם מאז שנת 1999, בהינתן שלא הכחישו את ידיעתם בדבר השימוש, יצרה רשות בלתי הדירה.

21. לגופו של עניין נטען כי החלל אותו פתח פאר הוא חלל בשטח של 2.5×3 מ"ר הצמוד למחסן שבבעלותו. לטענתו, המחסן משמש מעין סטודיו לנגינה, שם מנגנים בני משפחתו. כמו כן, לצורך פרנסתו כמורה לנגינה ניתנים שם שיעורי גיטרה. פאר טוען כי פריצת החלל נעשתה תוך השקעה כספית ניכרת והוא אף דאג לאקוסטיקה מתאימה, על מנת שהשימוש במקום לא יפריע לשאר בעלי היחידות. פאר מכחיש את כל הטענות בדבר תנועת תלמידים, רעש ואי סדר, וטוען כי מדובר בתלמידים ספורים בשבוע תוך הגבלת שעות הלימוד.

22. עוד טוען פאר כי הדרישה להחזרת החלל הריק לקדמותו הנה דרישה הנובעת מתוך צרות עין ומניעים נקמניים, כאשר מנגד לא נפגעה כל זכות קניינית של דוד, בשים לב למיקומו של החלל, צמידותו למחסן הנתבע ומאחר ולטענתו, אין בו כל ערך כלכלי לבעלי הרכוש המשותף, ולמעשה לא נפגעה זכות קניינית כלשהי שלהם.

23. באשר להצבת המזגן טוען פאר כי הוא מבקש למקם את מנועו מעל לכניסה למחסן ולא בחזית הבניין. לטענתו, מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, ועל כן אין צורך לקבל את הסכמת האסיפה הכללית. פאר מציין כי מגמת הפסיקה נוטה להקל בנושא התקנת המזגנים.

24. פאר טוען עוד כי דוד עצמם התקינו מזגן ללא קבלת הסכמות בעלי הדירות או כינוס האסיפה הכללית וללא כל אישור כדין. לטענתו, מנוע מזגן דוד הותקן בחזית הבית, באופן המכער את הבניין וגורם לרעש ומטרד לו ומשפחתו. פאר טוען כי במצב דברים זה, יהא זה עיוות דין וקיפוח אם ייאסר עליו להתקין גם הוא מזגן כמבוקש על ידו.

תיק 314/12

עיקרי טענות פאר

25. במסגרת תביעה זו טוענים פאר כי דווקא דוד הם אלו שעשו דין לעצמם, השתלטו על הרכוש המשותף ופגעו בו ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית וללא קבלת הסכמות כדין.

26. כן טוענים פאר כי דוד עצמם עשו שימוש בחלל שהיה צמוד לדירתם, המהווה רכוש משותף, וצירפוהו כחדר נוסף לדירתם (להלן: "חלל 2").



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

27. בהקשר זה פאר טוענים עוד כי דוד השתלטו על רכוש משותף נוסף הכולל מתחם בכניסה לדירתם וזאת באמצעות חלונות אלומיניום, והכל ללא קבלת היתר כדין ותוך שינוי חזות הבניין.

28. כך גם נטען כי דוד התקינו מנוע של מזגן בחזית הבניין, על גבי הרכוש המשותף, ללא כינוס האסיפה הכללית ומבלי שהיו בידם הסכמות כדין. נטען כי מנוע המזגן מוצב בחזית הבניין, גורם לפגיעה אסתטית וכן לרעש ומטרד לנתבעים ובני ביתם.

29. פאר טוענים עוד כי דוד הציבו ברכוש המשותף- שביל הגישה לדירות, שער ברזל אותו הם נוהגים לנעול, תוך ביצוע עבודות ופגיעה ברכוש המשותף. כן נטען כי דוד השתלטו על שטח הרכוש המשותף שמעבר לשער ונוהגים בו מנהג בעלים – משחקים משחקי כדור תוך גרימת רעש והפרעה לאורח החיים בבית.

30. פאר מבקשים להורות על מתן הסעדים הבאים:

" א. להסיר את מנוע המזגן אשר הותקן על הרכוש המשותף ולהתקינו או לא להתקינו ו/או לשנות את מיקומו רק לאחר קבלת החלטה על ידי האסיפה הכללית בהתאם להוראות כל דין.

ב. להסיר את שער הברזל אשר הותקן שלא כדין בשטח הרכוש המשותף והמונע גישה לשטח הרכוש המשותף.

ג. לסתום ולאטום את החלל אשר פרצו הנתבעים מדירתם לשטח הרכוש המשותף ולהשיב את המצב לקדמותו באופן ששטח דירת הנתבעים יהיה תואם לשטח הרשום במרשם המקרקעין.

ד. להסיר את החלונות והאלומיניום אשר התקינו בשטח הרכוש המשותף תוך שינוי חזות הבניין.

ה. להורות וליתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעים ו/או למי מטעמם מביצוע כל בניה ו/או עבודה ו/או הקמה ו/או תפיסת חזקה בלעדית וייחודית או שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף.

ו. ליתן כל הוראה ו/או צו ו/או סעד בהתאם לסמכות כבוד המפקח ועל פי הראיות שיובאו ו/או יוכחו בפני כבוד המפקח.

ז. לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד".

31. בסיכומיהם מוסיפים פאר וטוענים כי מכל מקום, פעולת הסגירה שינתה את חזותו החיצונית של הבית המשותף ולפיכך היה על דוד לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות לכך.

עיקרי טענות דוד

32. דוד טוענים כי כתב התביעה שכנגד הוגש בחוסר תום לב, באופן טורדני וקנטרני ולפיכך דינו להידחות.

33. לטענת דוד, לאחר שהתברר להם כי חלל 2 שצירפו לדירתם איננו שייך להם, השיבו את המצב לקדמותו. דוד מזכירים בהקשר זה כי דווקא פאר הוא שהשתלט על חלל המהווה רכוש משותף שלא כדין, אולם בניגוד אליהם ממשיך להחזיק בו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

34. באשר לשער הברזל נטען מפי דוד כי השער פתוח באופן קבוע. לטענתם, השער הותקן לפני כשבע שנים בהסכמת הדיירים ומטעם זה טענת פאר גם הועלתה בשיהוי ניכר. נטען עוד כי התקנת השער היא עשיית שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, בהתאם לתנאי הזמן והמקום.

35. בכל הנוגע למזגן, נטען כי המזגן איננו מרעיש, הוא ממוקם בחלק הפנימי של הבית ומרוחק מרחק רב מחלון ביתם של פאר.

36. ביחס לסגירת המתחם בכניסה לדירתם, טוענים דוד כי מתחם זה מהווה חלק בלתי נפרד מדירתם, ואיננו ברכוש משותף. כן נטען כי הסגירה היא פעולה סבירה בהתאם לתנאי הזמן והמקום.

ג. דיון והכרעה

תיק 94/12

37. נפתח בדיון בטענת הסמכות. כאמור, אחד הסעדים אשר נתבע בתביעה זו הוא מתן צו המורה על החזרת המחסן לייעודו המקורי והאוסר על הנתבע לקיים בו שיעורי נגינה. התובעים טענו בכתב התביעה כי: "מזה 13 שנה אנו סובלים מהפרעות הנגרמות בגין השימוש החורג במחסן רעש, תנועת תלמידים במשך כל שעות היום, לכלוך ואי סדר".

38. הנה כי כן, כעולה מכתב התביעה, העילות מכוחן מבוקשים סעדים אלו, הן עילות מתחום דיני הנוזיקין שעיקרן במטרד ליחיד.

39. מסקנה זו מתחזקת ביתר שאת לנוכח דבריו החוזרים ונשנים של התובע, מר עוזי דוד, בחקירתו מהם עלה כי הסיבה המרכזית להגשת התביעה היא המטרד, שלטענתו נגרם לו, מהשימוש במחסן – "זה מהווה מטרד ולכן החלטתי לפנות ולהגיש תביעה..." (ראה פרוטוקול מיום 17.1.13, עמ' 4 שורות 11-12), "... בכל מקרה הייתי מגיש תביעה. ראיתי שזה מטרד שתלמידים מגיעים לשביל של הבית שלי... (שורות 18-19), "... המטרד זה גם המחסן וגם הרחבת החדרים" (שורה 22).

40. סמכויות המפקח על המקרקעין קבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 הקובע:

" (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

(ד) **האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.**

41. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל. בד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כח 1, 730 (להלן: "פרשת שמע"), קבע כב' השופט זוסמן כי: "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

42. כך נקבע כי גם עילת המטרד אינה בגדר סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין (ראה למשל: ע"א 664/71, עורקבי ואח' נ' נקר, פ"מ ע"ח 130, ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1) 231).

43. מאחר ומניסוח כתב התביעה עולה כי היא נסמכת על עילת המטרד, ולכן אין בידי לקבל את טענת דוד, כי סמכות המפקחת קמה מכוח סעיף 2 לתקנון המצוי. לפיכך, הרי שאין בסמכותי לדון בסעדים אשר נסמכים על עילת המטרד היינו החזרת המחסן לייעודו והאיסור על קיום שיעורי נגינה בו.

44. בשולי הדברים יצוין עוד כי בפרשת שמע לעיל נקבע גם כי "שינויים בדירה" לעניין סעיף 2 לתקנון המצוי אינם שינויים בשימוש שנעשה בדירה, אלא הם שינויים בגוף הדירה שבעטיים ניוקה דירה אחרת או הרכוש המשותף (על משמעות ונפקות השינוי על דרך של סיפוח רכוש משותף לדירה נעמוד בהמשך, אולם כבר כאן יצוין כי בנסיבות המקרה דנן אין בהם בכדי לשנות מהתוצאה אליה הגעתי).

45. ליתר הטענות המקדמיות, ובעיקר לטענת השיהוי והמניעות, אדרש בהמשך הדיון.

46. נותר, למעשה, לדון בשני הסעדים הנוספים - החזרת החלל הריק לקדמותו, ואיסור על התקנת המזגן. נפתח בנושא החלל.

תפיסת חזקה ייחודית ברכוש משותף

47. כפי שעולה מסיכומי הצדדים, אין חולק כי החלל מהווה רכוש משותף. כך, גם מסכימים הצדדים ביניהם כי בפועל פאר עושים בחלל זה שימוש ייחודי.

48. המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלת חוקיות השימוש שעושים פאר בחלל. טענתם העיקרית של פאר בהקשר זה היא כי דוד מנועים ומושתקים מלטעון כנגד השתלטות זו שכן הם הסכימו לה, ופאר הסתמכו על הסכמה זו ושינו מצבם לרעה.

49. נפנה לבחינת המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לדיון זה.

50. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") כך:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

51. סעיף 55(ג) לחוק, דן בדרך הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה פלונית וקובע-

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד"

52. סעיף 62 (א) לחוק קובע:

"(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות (ההדגשה שלי- י.ע.ש).

53. סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי מורה כך :

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.

54. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מרכוש משותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף לבעל דירה פלונית.

55. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסויימת במרשם המקרקעין (ראה: ע"א 2525/92, גבי וקרני ראוכברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק- על 732 (2)87, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

56. על ההבחנה בין מתן "זכות קניינית", דהיינו ביצוע הצמדה, לבין "מתן רישיון לשימוש ייחודי" עומד המלומד א. אייזנשטיין, בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113-

"הצמדה" הנה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו - בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד... (ההדגשות במקור)

ראוי להדגיש כי שימוש פיזי בשטח מסוים של הרכוש המשותף במשך תקופה ממושכת אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש הצמדת שטח זה לדירתו. רק הצמדה הנעשית על פי הוראות החוק, מעניקה לו זכות קניינית בה".

(ראה גם- ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח', ניתן היום 7.8.07, פורסם ב"נבו").



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

57. פרופ' נ' זלצמן עמדה על הגדרתו של מוסד רשיון זה (במאמרה "רשיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24):

"רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע...."

כתבה פרופ' זלצמן על ההשתק הקנייני:

"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך" (נ' זלצמן "רשיון במקרקעין", שם, 30)

58. ההסכמה הנדרשת יכולה להיות גם בעל פה ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא. בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון, ע"א 815/81, יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בעל פה בין בעלי דירות בבית המשותף, הנוגעת למתן רשות לשימוש ברכוש המשותף, גם אם לא ניתן לה ביטוי רישומי בתקנון ובספר ההחלטות, וכך נקבע שם-

"... מובן מאליו, שהסכמה בעל-פה חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות. אם היא מוכחת כך, אין כל חשש לאי-ודאות. הרי סעיף 23 של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, מאפשר, בדרך כלל, עשיית חוזה כלשהו בהסכמה בעל-פה. אין לראות טעם, מדוע נכונות זו של המחוקק לתת תוקף להסכמה בעל-פה לא תחול גם על הסכמת בעלי הדירות בבית משותף לטובת אחד מהם..."

ראה לעניין זה גם: ע"א (חיפה) 1020/03, בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, תק-מח 2004(1), (להלן-"פרשת בובליל"), 5244, ע"א 19/81 בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח', פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פד"י לא (1) 382.

59. אולם, ההסכמה תחייב את בעלי הדירות האחרים רק אם ידעו על קיומה. בפרשת בובליל נאמר בהקשר זה כך-

" לעמדתי רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן לגבי כלפי הבעלים והן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות לכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיומו של ההסכם ורישומיו ניכרו היטב עקב הבינוי והנהוג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נהגת מוסכמת מקום לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין..."



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

60. כשעסקינן בהסכמה על דרך של מתן רשות לשימוש במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), הרי שניתן לחזור ממנה בכל עת. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בת.א. (ת"א) 2816/03, **ציפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפל**, (להלן: "**פרשת קונצ'יצקי**") ניתן ביום 3.4.06, פורסם ב"נבו".

" הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינום שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון :

" רשות שנלמדת מכלל לאינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינום המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני (פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב 24,57; וראה גם מ.דויטש קניין כרך ב' (התשנ"ט-414 1999))."

61. עם זאת נקבע כי במקרים מיוחדים בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מן ההסכמה ובהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעליו כספים רבים, תוענק הגנה לבעלי הרישיון (ראה: ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 **קוגלמס נ' קוגלמס**, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 **לוי נ' ויימן ואח'**, פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם באתר נבו)).

62. **בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי הדירות**, ניתן ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות- האחד כלפי משנהו- כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף. רישיון זה יהיה בלתי הדיר כאשר בעלי הדירות כולם או חלקם הסתמכו על שתיהן זו ושינו מצבם לרעה בעקבותיה.

63. חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות, החייבות, כאמור, להיעשות על דרך של הצמדה וקבלת תוקף רישומי לכך, בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק. כאשר קיימת **חלוקה מוסכמת** של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות שכן כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף.

64. אמנם, בפרשת קונצ'יצסקי נקבע כי "**בנייה בלתי חוקית נתונה, מעצם טיבה, לסכנת הריסה ואין הבונה רשאי לטעון לזכות הנשענת על הסתמכותו**", אולם נראה כי ניתן לאבחן קביעה זו שעה שמדובר בנסיבות בהן כל אחד מבעלי הדירות ביצע, בהמשך לאותה חלוקה מוסכמת ובהתבסס עליה, בניה ללא היתר בחלק אחר של הרכוש המשותף.

65. ודוק: בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור, בשונה ממתן רשות שימוש לבעל דירה מסוימת בלבד ברכוש המשותף, אין המדובר ב"חיתור" של בעל דירה על זכותו לעשות שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

אחרת בבית המשותף. שכן כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד- מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו. לפיכך, החזרה מהסכמה בדבר חלוקת שימוש כזו לא תעשה בנקל ושינויה של אותה חלוקה מוסכמת עשוי לחייב הסכמה חדשה בין בעלי הדירות לחלוקה אחרת (ראה: ע"א (תל אביב- יפו) 1791/08, לוי נ' טובה, ניתן ביום 23.1.12 (פורסם ב"תקדין")).

מן הכלל אל הפרט

66. על רקע זה יש לפנות לבחינת המקרה שלפנינו.

67. החללים המצויים בסמוך לדירות המבנה מהווים חלק מ"הרכוש המשותף" כהגדרתו בסעיף 52 לחוק. מדובר בהגדרה שיווית בעיקרה "כל חלקי הבית המשותף חוץ מהחלקים הרשומים כדירות", ובצידה פירוט- "לרבות..." משעה שחללים אלו לא הוצמדו לאף אחת מדירות הבית המשותף, יש לראותם כחלק מהרכוש המשותף.

68. במקרה הנדון קיים לבית המשותף תקנון מוסכם. על פי סעיף 22 לתקנון המוסכם של הבית המשותף "כל חלקי הרכוש המשותף שבתחומו של כל מבנה ומבנה, למעט הקרקע, יוצמדו ליחידות שבאותו מבנה". סעיף 32 לתקנון זה קובע כי: "הרכוש המשותף שאינו בתחומי המבנים יוצמד לכל יחידות הבית המשותף".

69. סעיף 44 לתקנון המוסכם קובע כי: "כל החלטה מכל סוג שהוא שנוגעת או הקשורה למבנה מסוים (גם לגבי החלטות בעלות אופי קנייני כגון הוצאת שטחים מהרכוש המשותף של אותו מבנה לרבות הצמדת שטחים לדירות וזכויות בנייה השייכות לאותו מבנה), תידרש הסכמה של בעלי היחידות באותו מבנה בלבד. בעלי יחידות במבנים אחרים יהיו פטורים מלתת הסכמתם כאמור לעיל".

70. החללים בהם עסקינן נמצאים בתחומי המבנה וניתן לראותם כחלק מן המסד שלו. לפיכך, מכוח התקנון המוסכם הם מהווים רכוש משותף המוצמד למבנה. מהתקנון המוסכם עולה כי לשם הקניית זכות קניינית בחלל או לחלופין עשיית שימוש ייחודי בו, די בקבלת הסכמות של בעלי הדירות במבנה ואין צורך בקבלת הסכמות כל בעלי דירות הבית המשותף. באשר לרוב הדרוש מבין בעלי דירות המבנה, אין באמור בתקנון המוסכם בכדי לשנות את קביעות החוק. קריאת סעיף 44 בתקנון המוסכם מלמדת כי אין בה בכדי לשנות את הרוב המהותי הנדרש בחוק אלא אך להבהיר כי יש לראות בכל מבנה כמעין "בית משותף" נפרד לצורך קבלת הסכמות המתייחסות לרכוש המשותף אשר צמוד לו. בסעיף זה לא נאמר "כל בעלי היחידות" אלא "בעלי היחידות" ללמדנו כי נדרשת הסכמת בעלי הדירות בהתאם לרוב הקבוע בחוק, ולא כל בעלי הדירות במבנה לכל דבר ועניין. (באגב יצוין כי פאר כלל לא טענו שמדובר בהרחבת דירה לפי סעיף 71 לחוק, שכן יש לראות את המחסן כדירה בהתאם להגדרת "דירה" בסעיף 54 לחוק, ולפיכך די בהסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. נראה כי טענה לא זו עלתה שכן ממילא, בשים לב



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

להוראות התקנון המוסכם, משמעות 3/4 מבעלי הדירות במבנה בו מצויים 3 דירות בלבד, הנה הסכמת כל בעלי הדירות).

71. במצב דברים זה יש לבחון האם ניתנה הסכמה בעל פה, או האם ניתן לראות בהתנהגות הצדדים במשך השנים, ככזו המלמדת על הסכמה מכללא. נפנה לבחינת נסיבות העניין.

72. התובע, מר עוזי דוד, העיד בתצהירו כי רכש את הבית בשנת 1999 מחברת "אשדר" (ראה בסעיף 4 לתצהיר עדותו הראשית מיום 2.12.12) וכי ידע אותה עת כי סמוך לדירתו וכן למחסן יש חלל המהווה רכוש משותף של כלל הדיירים (סעיף 7 לתצהיר). בתצהירו טען כי פאר השתלט על החלל הסמוך למחסן שלא כדין וללא הסכמת התובעים.

73. בחקירתו הנגדית הודה דוד כי הוא עצמו פרץ לחלל הממוקם בסמוך לדירתו, עת נכנס לדירה בשנת 1999, וזאת לאחר שהתברר לו כי פאר בעצמו סיפח חלל הסמוך למחסן שבבעלותו-

"ש. מתי פרצת את החלל והוספת אותו לדירתך?

ת. כשנכנסתי לדירה בשנת 1999.

ש. ולמה החלטת להוסיף את החלל הזה ולא אחר?

ת. כשנכנסתי לדירה נודע לי שהנתבע פרץ את החלל הריק, לחלל שצמוד למחסן שלי.

ש. ואז אמרת אם הוא פרץ לחלל שסמוך למחסן שלו, אני אפרוץ את החלל שסמוך לדירה שלי נכון?

ת. נכון אבל לא רציתי לגרום לסכסוך ולכן אמרתי שאני אפרוץ חלל קטן רק כדי להכניס לשם דברים, מחסנון קטן, וכך עשיתי".

(ראה בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 17.1.13, בשורה 41-45, וכן בעמ' 4 שורות 1-4).

74. כאמור לעיל, המבנה מונה שלוש דירות בשתיים מהן גרים דוד ופאר. הצלע הנוספת במשולש זה הם מר איתן שטיין (להלן: "שטיין") ורעייתו, הגרים ביחידת הדיור השלישית במבנה, הידועה כתת חלקה 36. שטיין הגיש תצהיר עדות ראשית מטעם פאר. בתצהירו ציין כי עבר להתגורר בבניין בתחילת 1999, לאחר פאר ולפני דוד (ראה בסעיף 5 לתצהירו). שטיין הצהיר עוד כי: "ידוע לי שהתובעים (דוד- י.ע.ש) פעלו בהתאם להמלצת נציג הקבלן ופתחו חלל הסמוך לדירתם והוסיפו שטח לדירתם. הנתבע גם הוא, בשים לב לכך שדירתו מצויה בקומה העליונה, פתח חלל שהיה קרוב למחסן המוצמד לדירתו ונמצא בקומת הקרקע" (ראה בסעיף 7 לתצהירו).

75. בחקירתו, הבהיר שטיין כך- "... נקודה שנייה זה שבפעם יש שם חללים שהיו מתחת למבנה ולמעשה כל אחד עשה שימוש בחלל אני חושב שזה היה בידיעה של כולם אבל לא נעשה באישור פורמאלי. אני גם עשיתי את זה ואין לי היתר על כך" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 17.1.13 עמ' 14 שורות 2-4).

76. דוד עצמו בסוף חקירתו, אישר כי השתלטות פאר על החלל הייתה בהסכמת יתר בעלי הדירות, למצער במבנה -



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

77. " ש. תאשר לי שלגבי שהחלל של מחסן הנתבע הייתה בין השכנים הסכמה הן לגבי השימוש והן לגבי ההשתלטות?

ת. הייתה הסכמה לגבי ההשתלטות אך לא לגבי השימוש" (בעמ' 8 שורות 43-45).

78. הנה כי כן, מהראיות שהובאו בפני עולה תמונה עובדתית ברורה לפיה כבר בסמוך למועד אכלוס דירות המבנה, בשנת 1999, פתח כל אחד מבעלי הדירות בו את החלל הצמוד וסיפחו לדירתו- כך עשו דוד, כך עשה גם פאר (ביחס לחלל הצמוד למחסן) ובאופן דומה פעל גם בעל יחידת הדיור השלישית, שטיין. עוד עולה כי אף אחד מבעלי דירות המבנה לא קיבל היתר בנייה לשם סיפוח החלל הצמוד לדירתו.

79. למקרא החומר ולמשמע העדויות שוכנעתי כי במשך 13 שנים עשה כל אחד מבעלי הדירות שימוש ייחודי בחללים הסמוכים לדירותיהם, תוך שכל אחד מבעלי הדירות האחרים ידע והסכים לכך, גם אם הסכמה זו נעשתה על דרך השתיקה.

80. יתרה מכך: מעדותו של דוד עלה כי הוא סגר את חלל 2, אשר סיפח לדירתו, רק בסמוך להגשת כתב התביעה. בהתייחסו למועד בו סגר את החלל בדירתו אמר דוד כי- "אחרי כתב התביעה החלל היה סגור. לא זוכר אם סגרתי לפני או אחרי הגשת התביעה" (שורה 7) ובהמשך הוסיף בהתייחסו למועד סגירת החלל בדירתו- "זה קרה אחרי 13 שנה כיוון שהחלטתי לתבוע את השכן על כך שזה מהווה מטרד ושהוא גם הולך לתבוע אותי" (שורות 25-27).

81. העובדה כי שטיין, אשר אף הוא סיפח לדירתו את החלל הצמוד, איננו כלל צד לסכסוך מעידה אף היא, כי לב המחלוקת עניינה, כפי שציינתי בפתח הדברים, המטרד הנגרם לדוד, לטענתם, מהשימוש במחסן כחדר ללימוד נגינה ולא עצם השימוש בחלל המהווה רכוש משותף.

82. מכל מקום, הוכח בפני שלא זו בלבד שדוד לא מחו בפני פאר כנגד החזקה הייחודית בחלל המצוי בסמוך למחסן אלא רק כשלוש עשרה שנים לאחר מכן ורק על דרך של הגשת תביעה, אלא גם שהם עצמם נהגו במשך כל אותה תקופה באופן דומה, היינו סיפחו בעצמם את חלל 2 לדירתם וסגרו את החלל רק בעקבות הגשת התביעה. כאמור, סיפוח החלל על ידי כל אחד מבעלי דירות המבנה נעשתה בהסכמה או לכל הפחות בידעיהם והסכמה שבשתיקה בין כל בעלי הדירות גם יחד.

83. התמשכות חלוקה זו החל משנת 1999 יצרה ציפייה לגיטימית כי הסדר זה ימשיך גם בעתיד. אגב חלוקה זו, הושקעו כספים ומאמצים לשם סיפוח החללים ושימוש בהם.

84. לפיכך, מנועים דוד מלטעון כעת להשתלטות ולהיעדר הסכמתם לשימוש שעושים פאר בחלל.

85. לתוצאה זה נגיע גם מכוח החובה לנהוג בתום לב ביחסים שבין בעלי דירות בבית המשותף.

86. בפסק דין אשר יצא לאחרונה מידי בית המשפט העליון – ע"א 8661/10, יוסף נעמה נ' תמר טורקיה (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 19.2.12), עמדה כבוד השופטת חיות על כך שעל אף שאין חולק בדבר מעמדה החוקתי של ההגנה על זכות הקניין, יתכנו מקרים בהם מכוח עקרון תום הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בעל זכות קניינית. באותו מקרה, נשללו הסעדים המבוקשים של הריסת הבניין וסילוק ידה של המשיבה בחלק משטח הפלישה, וזאת על אף ששטח הפלישה היה בבעלותו הבלעדית של המערער. בעניין זה נאמר מפי כבוד השופט חיות כך:

"... על החובה לפעול בתום לב ועל היקף פרישתה במשפט הישראלי, עמד בית המשפט לא אחת בציינו כי זוהי אחת מאותן דוקטרינות כלליות החלות בכל תחומי המשפט על פיה, כל בעל זכות (במובנה הרחב) צריך להפעיל את זכותו בתום לב...אכן, ההגנה על הקניין מפני פגיעה יש לה מעמד חוקתי... יחד עם זאת, בעלים של נכס ובכלל זה נכס מקרקעין, אינו נהנה מאוטונומיה מוחלטת בבואו להגן על החזקתו בנכס ואין לו זכות בלתי מסויגת ל"שרירות בעלים"... יתכנו, אפוא, מקרים שבהם מכוח עקרון תום הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל זכות קניינית, הגם שזו נפגעה על ידי הזולת... מנגנון מאזן ברוח זו הנותן ביטוי לעקרון תום הלב אנו מוצאים בסעיף 14 לחוק המקרקעין הקובע כי "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין אין בהן לכשעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר"... בעל דין המבקש לעמוד על זכויותיו מחוייב מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר..."

87. ברע"א 6339/97, רוקר נ' סלומון, פ"ד נה (1) 199 (להלן: "עניין רוקר"), התייחס כב' הנשיא (כתוארו אז) ברק להיקף שיקול הדעת המסור לבית המשפט בכל הנוגע להגנה על זכות הקניין ואל השיקולים אשר יש בהם להשפיע על אופן החלתו של עקרון תום הלב. הנשיא ברק עמד על הצורך ליתן ביטוי לטיב היחסים המתקיימים בין בעל הקניין לזולתו בהדגישו כי "לא הרי מעמדו של תום הלב ביחסים בין בעל קניין לזר, כהרי מעמדו של תום הלב ביחסים בין בעל קניין לשותפו; לא הרי הפגיעה על ידי אדם שהקשר עמו הוא חד פעמי (כגון מסיג גבול מזדמן) כהרי פגיעה על ידי אדם שהקשר עמו נמשך (כגון דייר בית משותף)". אמות המידה המנחות אשר נקבעו בעניין רוקר הן בין היתר: עוצמת הזכות הקניינית שנפגעה; עוצמת הפגיעה בזכות לרבות משכה והיקפה; עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה; מהות היחס עם הזולת ומידת צפיותיו והסתמכותו (ראו: פסק דינו של כב' השופט טירקל בעמ' 242-243, פסק דינו של כב' הנשיא ברק בעמ' 279).

88. בנסיבות המתוארות לעיל יש משום היעדר תום לב בטענת דוד כי פאר השתלטו על רכוש משותף בדמות סיפוח החלל למחסן, וכן בטענה כי הם עצמם החזירו את המצב לקדמותו. אמנם, בביקורי במקום נכחתי כי אכן חלל 2 נסגר באמצעות קיר גבס, אולם מהראיות שהובאו בפניי נראה כי חלל זה נסגר (באופן העשוי להיות ארעי בלבד) בעקבות הגשת תביעה זו, ומכל מקום- כי במשך שנים ארוכות נהגו דוד באופן זהה לפאר בכל הנוגע בשימוש בחללים הצמודים לדירותיהם ומהווים רכוש משותף.

89. לאור האמור, נוצרה לדוד מניעות לחזור בהם מהסכמה זו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

התקנת המזגן

90. על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, זכאי בעל דירה לעשות ברכוש המשותף שימוש שהוא "רגיל וסביר", התואם את ייעודו של הרכוש המשותף, בהתאם ל"תנאי המקום והזמן", או על פי כוונת הצדדים, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות שימוש זהה. לשם כך, אף אין צורך לקבל את הסכמת האסיפה הכללית (ראה גם: ע"א 708/72, פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2) 817, ע"א 458/82, וילנר נ' גולני, פ"ד מב (1) 49, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

91. מגמת הפסיקה נוטה היום להקל בנושא התקנת המזגנים ולהתייחס אליה כאל שימוש "רגיל וסביר", בהתחשב בתנאי האקלים הארץ-ישראליים. כאשר אין פגיעה בשלמות המבנה או תקינותו וכל עוד אין המדובר בפגיעה חזותית ניכרת או כל פגיעה מהותית אחרת, לרבות רעש, הנטייה היא אכן לראות בהתקנת המזגן שימוש רגיל וסביר.

92. יפים בהקשר זה גם דברים שנאמרו בע"א (מחוזי י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל ואח' (ניתן ביום 4.4.02, פורסם ב"נבו").

"בשנים האחרונות מסתמנת בפסיקת המפקחים על רישום המקרקעין מגמה לראות, בנסיבות מסוימות, התקנת מזגן כשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בכפוף לתנאי הזמן והמקום. דעתנו היא, שיש לעודד מגמת פסיקה זו לאור תנאי האקלים בארץ. כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל"

ראה גם: ע"א (ת"א) 991/97, נציגות הבית המשותף נ' אבן (ניתן ביום 13.1.98, פורסם ב"נבו").

93. במקרה הנדון, מהביקור שערכתי במקום התרשמתי כי פאר מבקשים להתקין מזגן מעל הכניסה למחסן, בקומת הקרקע ובפתח המעבר המשותף המוביל לדירת דוד (שביל הגישה עצמו מהווה רכוש משותף שאינו מצוי בתחום מבנה מסוים (שכן הוא משרת יותר ממבנה אחד) ולפיכך, מכוח סעיף 33 לתקנון המוסכם, הוא מהווה רכוש משותף של כלל הבית המשותף). התרשמתי עוד כי המרחק בין מיקומו המיועד של המזגן אל דירת התובעים גדול דיו על מנת לאיין את החשש ממפגע בולט של רעש ממנוע המזגן. עוד מצאתי כי מנוע המזגן, המיועד להיבנות בסמוך לכניסה, עתיד להיות מותקן בחלק פנימי של קירותיו החיצוניים של המבנה, כך שלא יבלוט בצורה שתגרום לפגיעה אסתטית חמורה בחזותו.

94. בנסיבות אלו, יש בהתקנת המזגן משום שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. יתרה מזאת, אף אם יש צורך בקבלת הסכמה של רוב בעלי דירות הבית המשותף באסיפה הכללית (בהתאם להוראת סעיף 2א לתקנון המוסכם הקובע כי: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה"), הרי שלאור סעיף 4 לתקנון המוסכם, באשר להתקנת המזגן על



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

קירותיו החיצוניים של המבנה, נדרשת הסכמת בעלי הדירות שבאותו מבנה בלבד. מהראיות שהובאו בפני נראה כי לא יקשה על פאר לקבל את הרוב הדרוש שכן היות ומדובר בשלוש דירות בלבד, די בהסכמתם ובהסכמת שטיין.

95. מכל מקום, על פאר לוודא כי המזגן, ככל שיותקן על קירותיו החיצוניים של המבנה בסמוך לכניסה למחסן, יהיה מזגן "קטן" בהספק של לא יותר מ-1 כוח סוס ושקט ככל הניתן.

תיק 314/12

96. מהטעמים עליהם עמדתי לעיל- גם דרישתם של פאר לסתימת ואיטום חלל 2 אשר פרצו דוד מדירתם - נדחית. האמור לעיל ביחס לחלוקה מוסכמת של החללים אשר נהגה בין בעלי דירות המבנה, יפה גם ביחס לפאר, ואף הם, בדומה לדוד, אינם יכולים לחזור בהם מהסכמתם לעשיית השימוש בחלל 2. ממילא, נראה כי דרישה זו של פאר נועדה אך להוות משקל נגד כנגד תביעתם של דוד, כאשר טענות אלו לכשעצמן- במצב עובדתי בו פאר עצמם השתלטו על חלל המהווה רכוש משותף, אינן עולות בקנה אחד עם חובת תום הלב החלה גם עליהם.

97. באשר לסעד המבוקש שעניינו בהסרת המזגן אשר התקינו דוד על חזית הבית המשותף והתקנתו רק בהתאם להחלטת האסיפה הכללית- הרי שגם אותו מצאתי לנכון לדחות. מהראיות שהובאו בפני עולה כי הן דוד והן פאר התקינו מזגן על קירותיו החיצוניים של המבנה, ושניהם עשו זאת ללא מחאה מצד בעלי דירות אחרים במבנה וללא כינוסה של האסיפה הכללית. בביקור שערכתי במקום לא מצאתי כי יש בהתקנת המזגן במקום בו הותקן משום פגיעה חזותית ניכרת ואף לא הוכח בפני כי מדובר במזגן רועש בצורה חריגה (אעיר כי לא הובאה בפני כל חוות דעת מומחה או אחרת המעידה על רעש החורג מן התקן המחייב). נוכח האמור לעיל ומגמת הפסיקה על פיה בהיעדר טעמים מיוחדים יש לראות בהתקנת המזגן כ"שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף, נדחה גם סעד זה.

98. בנוגע להסרת חלונות האלומיניום מחזית הכניסה לדירת דוד: מתשריט הבית המשותף עולה כי החלק עליו הותקנו חלונות האלומיניום שהסרתם מתבקשת, הוא חלק מדירת דוד. מדובר במבואת הכניסה לדירתם ולפיכך- אין עסקינן בהשתלטות על רכוש משותף כלל. טענתם החלופית של פאר בהקשר זה היא כי מדובר בפגיעה בחזות המבנה המצריכה הסכמתם של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. בביקורי במקום התרשמתי כי אין מדובר בפגיעה חזותית וכי קירותיו החיצוניים של הבית נותרו כשהיו, אולם הוספו להם חלונות בלבד. כמו כן כניסה זו מצויה בחלק פנימי של המבנה שכמעט ואיננו נצפה מבחוץ, וגם משום כך מצאתי כי אין מדובר בפגיעה חזותית. אשר על כן, נדחה גם סעד זה.

99. באשר לסעד הנוגע להסרת שער הכניסה למבנה-, עיון בראיות שהובאו בפני והתרשמותי מהביקור שערכתי במקום, מעלים כי השער איננו נעול אלא פתוח לרווחה ואיננו מונע את מעבר יתר בעלי הדירות. יחד עם זאת, תשריט הבית המשותף מלמד כי שביל הגישה לדירות המבנה הנו רכוש משותף של כלל הבית משותף ולא של המבנה לבדו (בפועל הוא משרת בעלי דירות נוספים מעבר לבעלי הדירות במבנה). כך עולה מסעיף



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33 לתקנון המוסכם הקובע כי "הרכוש המשותף שאינו בתחומי המבנים יוצמד לכל יחידות הבית המשותף". על מנת לבצע בניה כלשהי ברכוש המשותף, נדרשת, אם כן, הסכמת האסיפה הכללית לכך (ראה בסעיף 2 לתקנון המצוי). לפיכך, אני מורה כי שער הכניסה יוכל להיות במקומו ככל שתקבל החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות המאשרת זאת. אם תוך 60 יום לא תתקבל החלטה כאמור, על דוד להסיר את השער.

ד. הערות לפני סיום

100. קביעותי לעיל מתייחסות לפן הקנייני בלבד ואין בהן משום הבעת עמדה כלשהי בכל הנוגע לטענות דוד באשר למטרד הנגרם להם משימוש במחסן כחדר ללימוד נגינה, על השלכותיו השונות של שימוש זה (כגון תנועת תלמידים, רעש, לכלוך, וכיוצא בזה). כל טענותיהם של דוד בהקשר זה שמורות להם בפני בית המשפט המוסמך.

101. כמו כן, ומאחר וקביעותי עניינן במסגרת דיני הקניין בלבד, אין בהן משום היתר כלשהו לבניה הדורשת היתר לפי דינים אחרים (כגון דיני התכנון והבניה).

102. אדגיש עוד כי אין באמור בפסק הדין משום הקניית זכות קניינית כלשהי בחללים למי מהצדדים. החללים נשארים רכוש משותף של כל בעלי הדירות כל עוד לא יינתן צו מבית המשפט המוסמך המורה אחרת.

103. צר לי כי הצדדים לא הצליחו להגיע לעמק השווה בנושא הצבת המזגן במחסן, שכן התרשמתי כי זהו לב לבה של המחלוקת. מכל מקום, על מנת ליתר הליכים נוספים בערכאות המשפטיות, טוב יעשו הצדדים אם יגיעו ביניהם להסכמה באשר למיקום המדויק בו יותקן מזגן זה וככל הניתן, אף בסיועו של שטיין (אשר הביע לא אחת הסכמתו לגשר בין הצדדים במחלוקת זו).

ה. סוף דבר

104. התביעה בתיק 94/12- נדחית, בכפוף לאמור בסעיף 95 לפסק הדין.

105. התביעה בתיק 314/12- נדחית, למעט הסעד הנוגע להסרת השער- הותרת השער על כנו מותנית בקבלת אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 99 לפסק הדין.

106. בנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ח ניסן תשע"ג, 8 אפריל 2013, בהיעדר הצדדים ונשלח לצדדים בדואר רשום.

יעל עמנואל-שרון
מפקחת על רישום המקרקעין